



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 573/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

- התובעים: 1. שמואל אשכנזי
2. אסתר אשכנזי
ע"י ב"כ עוה"ד אבריאלה לסלו
ממגדלי ויטה, דרך בן גוריון 11, בני ברק

- נ ג ד -

- הנתבעים: 1. חיה פינקלשטיין
2. חנה (חני) פינקלשטיין
שתייהן מרחוב אינשטיין 4 רמת גן

ה ח ל ט ה

בפני תובענה שעניינה בבית ברחוב אינשטיין 4 רמת גן הבנוי על חלקה 570 בגוש 6144 (להלן: "הבית"). הבית רשום כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים ועל ניהולו חל תקנון מוסכם.

התובעים, חוכרים של תת חלקה 8 בבית, טוענים כי הנתבעים, חוכרת של תת חלקה 4 וביתה, מפירים הסכם בן למעלה מ- 50 שנה לחלוקת השימוש והחזקה בחצר הרכוש המשותף המקיפה את הבית. מכח ההסכמה רכשו התובעים גם זיקת הנאה מכוח שנים להחזיק ולהשתמש באופן בלעדי בחצר הצפונית ובמחצית החצר המערבית (להלן: "חצר התובעים"). בהתאם להסכמות מגודרות החצרות במשך עשרות שנים. הנתבעות ביצעו הרחבה לדירתם ובמקביל החלו להשתמש גם בחצר התובעים ולבצע עבודות לפתיחת פתח יציאה לחצר זו. במקביל הוצבו על גג תוספת בניה שביצעו הנתבעות, ואשר אמורה לשמש להרחבה עתידית של דירת התובעים, מנועי מזגנים ודודי שמש אשר אף גרמו לתובעים לנזקים. הנתבעים פעלו לקבלת היתר בניה לפתיחת פתח מדירתם לחצר התובעים ובמקביל אינם מאשרים כי לתובעים זכות לבנות על גג תוספת הבניה ללא תשלום כלשהו.

התובעים עותרים למתן צו הצהרתי בדבר זכותם בחצר התובעים ולמתן צו מניעה קבוע שימנע מהנתבעות להחזיק ולהשתמש בחצר זו או למנוע השימוש על ידי התובעים. בנוסף התבקש צו אשר יורה לנתבעות לסלק את דודי השמש, הקולטים והמזגנים מגג תוספת הבניה ולהרוס את הקורה שנבנתה על הקרקע. עוד נתבקש צו הצהרתי לפיו זכאים התובעים להצמיד את גג תוספת הבניה לדירתם ללא תשלום כלשהו לנתבעים.

לאחר שבחנתי בקפידה יתרה את כתב התביעה המפורט הגעתי למסקנה כי אין למפקח על רישום מקרקעין סמכות לדון בתובענה.

סמכותו של המפקח על רישום מקרקעין להכריע בסכסוכים נקבעה בסעיף 72 לחוק המקרקעין תשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין") הקובע:
"72. (א) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון או לפי סעיפים 58, 59 או 59א עד 59ח, לפי חוק המקרקעין (חיווק בתים משותפים מפני רעידות אדמה),



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 573/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התשס"ח-2008 או לפי סעיפים 6 נט עד 6 סא, 21 ב ו-27 ג לחוק הבזק, תשמ"ב-1982 יכריע בו המפקח.

(ב) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף, רשאי התובע להביאו, לפי בחירתו, לפני בית משפט מוסמך או לפני המפקח.
(ג) האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחול גם במקרה שמחזיק הדירה מטעם בעל הדירה או המתחזק הוא צד לסכסוך, ואם היתה דירה מוחכרת בחכירה לדורות או בחכירת משנה לדורות - גם אם צד לסכסוך הוא המחכיר לדורות או מחכיר המשנה לדורות.
(ד) האמור בסעיף זה אינו גורע מתקפו של הסכם למסור סכסוכים כאמור להכרעת בורר"

בתי המשפט נתנו פירוש דווקני לסעיף 72 המצוטט לעיל וקבעו כי אין להרחיב את פירושו.

כפי שנקבע בד"נ 20/73 שחנע נגד סדובסקי ואח' פ"ד כ"ח (1) עמ' 730 בעמ' 733 מפי מ"מ הנשיא זוסמן (כתוארו אז): "סעיף 72 לחוק המקרקעין...מרחיב אמנם את סמכותו של המפקח, היכול עכשיו לדון גם בתביעת נזיקין בעילה של הסגת גבול, ולענין זה נעשתה סמכותו מקבילה לזו של בית המשפט, אך... אין הוא רשאי לדון בתביעות נזיקין אחרות".

לחיזוק טיעון זה יש להוסיף כי הלכה פסוקה היא שגם עילות המטרד והיפר חובה חקוקה אינן בסמכותו של המפקח. (ראה ע"א 664/71 עורקבי ואח' נגד נקר פ"מ ע"ח 130 וכן ע"א 458/69 שליש נגד גולדברג פ"ד כ"ד (1) 231).

העולה מכך הוא כי משרצה המחוקק להעניק למפקח סמכות לדון בעילה מסויימת, עשה זאת במפורש ומכאן, כאשר עילות אחרות אינן מוגדרות במפורש בחוק המקרקעין, הן אינן בסמכותו של המפקח.

תקנה 78 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), התשע"ב - 2011 אמנם מחילה את תקנות סדר הדין האזרחי בשינויים המחוייבים על סדרי הדין בפני המפקח בכל ענין שלא נקבעה לגביו הוראה אחרת בחוק או בתקנות המקרקעין. אולם אין בכוחו של מחוקק המשנה אשר התקין את תקנה 78 להעניק למפקח סמכות עניינית שלא ניתנה לו בחוק המקרקעין על ידי המחוקק הראשי.

אומנם, הצדדים הינם חוכרי דירות בבית משותף. אומנם, הסכסוך שבניהם נוגע לשימוש ברכוש המשותף. אולם, עילת התביעה במקרה דנן ומקורו של הסכסוך הינם בחלוקת השימוש ברכוש המשותף על פי נוהג והסכמה של שנים.

סכסוך המבוסס על הסכם או נוהג בנוגע לחלוקת השימוש ברכוש המשותף של הבית אינו סכסוך המבוסס על תקנון. הוא גם אינו סכסוך המבוסס על הוראות חוק המקרקעין. הסכם מהווה התחייבות חוזית רגילה עליה חלים דיני החוזים. דיון בתובענה יחייב, מגיה וביה, דיון בסוגיות חוזיות העולות או הקשורות בהסכמת החלוקה - כך, תדרש פרשנותה של ההסכמה לרבות התייחסות לביצוע או הפרה על ידי מי מהצדדים. כך תדרש ההכרעה האם ההסכמה בכלל מחייבת את הנתבעות דנן.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 573/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

חוק המקרקעין אינו מקנה למפקח סמכות לדון בתובענות שעניינן הסכמים והתחייבויות רגילות שבין בעלי דירות בבית, שאינן בגדר תקנון.

זאת ועוד. בבית ישנם עוד בעלי דירות אשר גם להם חלקים ברכוש המשותף שבו מבקשים התובעים להגדיר זכויות שימוש ייחודיות. דא עקא, בעלי דירות אלו לא צורפו לדיון בהליך שבפני ומשכך ברור כי אין המדובר בסכסוך שעניינו בהוראות תקנון הבית.

וידוגש, אף אם היו התובעים מצרפים את כל בעלי הדירות להליך שבפני, כאשר עילת התביעה הינה לחלוקת השימוש הייחודי ברכוש המשותף בבית (אף ללא קשר להסכמות הנטענות), עדין לא היתה התובענה מצויה במסגרת סמכותי העניינית בהתאם להוראות סעיף 72 לחוק המקרקעין הנ"ל.

גם עיון בסעדים המבוקשים בתובענה מלמד על כי אינני מוסמך לדון בה.

ההכרעה המרכזית הנדרשת בהליך דנן הינה בדבר קביעת זכויות שימוש בלעדיות בשטח חצר התובעים הרשומה בפנקס הבתים המשותפים, נכון לעת הזו, כרכוש משותף. כך, הסעד הראשון המבוקש במסגרת התובענה הינו **הצהרה כי לתובעים זכות שימוש בלעדית** בחצר התובעים ומניעת שימוש מאחרים (סעיפי 29א עד 29ג לכתב התביעה). למעשה, **הסעד האמור משמעו אכיפת הסכם החלוקה**, שכן ההצהרה המבוקשת מתבססת על חלוקת זכויות השימוש הבלעדיות בהסכמות לאורך שנים ומתן זכויות שימוש ייחודיות בהתאם. סעד זה, מעצם טיבו, טבעו וניסוחו, הינו סעד הקשור, מניה וביה, בדיון בהסכמות החלוקה ובהכרעה משפטית ועובדתית לגביו.

מכל האמור עולה כי המדובר, למעשה, בתביעה לאכיפת הסכמות בדבר זכות שימוש במקרקעין, תביעה בה אינני מוסמך לדון. אינני מוסמך לדון בתובענה גם אם המדובר בתביעה לחלוקה יחודית של השימוש ברכוש המשותף מכח נוהג של שנים.

גם הסעדים האחרים המבוקשים אינם מצויים בגדר סמכותי העניינית.

אומנם, בעילת התביעה שעניינה הסגת גבול, וכפועל יוצא סילוק בניה שבוצעה (סעיפים 29ד ו-29ה לכתב התביעה) מוסמך אני לדון בהתאם להוראות סעיף 72(ב) לחוק המקרקעין כאמור. אולם, התובענה בהקשר זה והסעדים המבוקשים נגזרים, מניה וביה, מן הסעד הראשון הנתבע בדבר הכרה בזכות השימוש הייחודית של התובעים בחצר התובעים. בעיקר משטח זה מבוקש סילוק ידם של הנתבעים. כל הכרעה בעילת תביעה זו תחייב, קודם לדיון בה, הכרעה בדבר תוקפו של הסכם החלוקה או נוהג החלוקה הקיים והכרה בזכויות השימוש הייחודיות הנטענות של התובעים.

זאת ועוד. אף אם חלק מהתביעה אכן עוסק בהסגת גבול כאמור, הרי שקיימת בעניין זה, ממילא, סמכות מקבילה גם לבית משפט השלום (בהתאם להוראות סעיף 72(ב) לחוק המקרקעין לעיל). גישת הפסיקה היא שיש להעדיף את האפשרות שאינה גורמת לפיצול הדיון בפני מספר ערכאות. כך גם נקבע בבית המשפט המחוזי בתל אביב ע"י כב' השופטת גרסטל, בע"א (ת"א) 2295/01 מנחמי בוני מגדלי דוד ר"ג בע"מ נגד נציגות הבית המשותף ברחוב ז'בוטינסקי 138 ברמת גן ואח' (לא פורסם): "...ספק רב אם ניתן להעביר חלק מהתביעה לבית משפט אחר, בעוד שחלק אחר נותר



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 573/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

לדיון בפני המפקחת". במיוחד אמורים הדברים במקרה דנן בו ישנו קשר הדוק וישיר בין העילה החוזית – הכרה בזכויות השימוש היחודיות, לבין העילה הנזיקית בדבר הסגת גבול כאמור לעיל.

בכל הקשור לסוגית הבניה על גג תוספת הרחבת הבניה בדירת הנתבעות הרי שמדובר בתובענה שהקדימה את זמנה בהעדר כל פעולה ממשית של התובעים לביצוע הבניה. מכל מקום, גם תובענה זו, ככל שיהיה בה צורך בבוא הזמן, תחייב צירוף של כל אותם בעלי דירות המתנגדים לבניה (שבעת הזו כלל איננה מתוכננת וממילא לא ברור אם ישנם בכלל מתנגדים כלשהם).

ובהקשר זה יודגש כי גם כל הקשור בסוגית השתתפות בהוצאות בניה והרחבה (לרבות בניה על גבי הרחבה קיימת) ממילא אינו מצוי בגדר סמכות המפקח (652/12 אלדד סינמן נ' יאיר שמריהו (פורסם באתר משרד המשפטים)).

לאור כל האמור לעיל אני קובע כי אינני מוסמך עניינית לדון בתובענה דנן.

בפסק דין שניתן בבית המשפט המחוזי בת"א ע"י כב' השופטת חיות ב- ע"א 1730/99 ז.ה.ר בע"מ ואח' נ. יום טוב בע"מ (לא פורסם) נקבע כי למפקח על רישום מקרקעין יש סמכות להעביר תביעות לבית משפט השלום: "בנסיבות אלה, לא היה מקום לדחות (ע"י המפקח - א.ס.) את העתירה החילונית שהעלו המערערות והיה זה מן הראוי להעתר לה ולהעביר את התביעות שבנדון לבית משפט השלום המוסמך, על מנת שהמערערות תוכלנה להביא את תביעותיהן בפניו".

חיזוק לעמדות אלה נמצא במאמרה של כב' נשיאת בתי משפט השלום במחוז תל אביב - יפו, השופטת עדנה בקנשטיין, במאמרה "הלא יעבירו עוד?", עלי משפט כרך ה' מרץ 2006 (תשס"ו), 7.

לאור האמור לעיל, ובהתאם להחלטה שניתנה בבית המשפט המחוזי בתל אביב ע"י כב' השופט ד"ר קלינג בת"א (ת"א) 1098/01 פיק נכסים בע"מ נגד נציגות הבית המשותף תק - מח 2002 (2) 3071, למפקח על רישום מקרקעין ישנה הסמכות בהתאם להוראות סעיף 79(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד - 1984, להעביר תביעה, שאינה בסמכותו, לבית המשפט המוסמך.

לאור האמור לעיל, ולאור היות הסמכות לדון בתובענה נתונה לבית משפט אחר, אני מורה, בהתאם לסעיף 79(א) הנ"ל, על העברת התביעה לדיון לבית-משפט השלום בתל אביב המוסמך לדון בתובענה.

משנתקבלה החלטתי זו כאמור על בסיס כתב התביעה בלבד, עוד בטרם הומצא לנתבעים, אינני מוצא מקום ליתן צו להוצאות.

ככל שלצורך ניהול ההליך בבית משפט השלום ידרשו התובעות לשלם אגרת תביעה, אני מורה על החזר האגרה ששולמה בהליך דנן בכפוף להמצאת קבלה בגין תשלום האגרה בבית משפט השלום כאמור לעיל.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 573/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

המזכירות תמציא החלטה זו לצדדים בדואר רשום.

ניתנה בלישכתי ביום כ"ט כסלו תשע"ד, 02 דצמבר 2013, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב